

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS II

A legalidade aparece em mais de um ponto da Constituição, tais como nos arts. 5º, 37 e 150. Na presente aula, será abordada a legalidade em sentido amplo, dirigida aos cidadãos. Observa-se o que dispõe o inciso II do art. 5º:

Art. 5º (...) II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

A legalidade dirigida aos cidadãos é ampla, de modo que o sujeito pode fazer o que não houver lei proibindo.

Legalidade ampla x estrita (administrativa)

Na legalidade administrativa, o administrador só pode agir quando houver lei permitindo. Essa concepção tradicional vem, pouco a pouco, sendo substituída pelo princípio da juridicidade, segundo o qual o agente público deve agir de acordo com todo o ordenamento jurídico. Por exemplo, as agências reguladoras, tais como Aneel, Anatel, Anvisa e Anac, são autarquias ligadas ao Poder Executivo e têm poder normativo, editando atos normativos que devem ser seguidos pelo agente público. Entre esses atos, está a resolução da Anac que limita a 10kg a bagagem de mão. Assim, a juridicidade é mais ampla do que a própria ideia de legalidade.

Legalidade x reserva legal

A legalidade abrange as normas a serem observadas, ou seja, exige a lei em sentido amplo. Por outro lado, a reserva legal exige lei em sentido formal (estrito). Por exemplo, a proibição de criar crime por meio de medida provisória é parte do princípio da reserva legal. Um crime só pode ser criado por meio de lei em sentido estrito.

Existe hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares? Parte da doutrina indica que existe, mas, no âmbito da doutrina e da jurisprudência do STF, o que prevalece é o entendimento de que não existe hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares.



5m

ANOTAÇÕES

A primeira diferença entre as duas é que, quando a Constituição pede lei complementar, a exigência é explícita: 'na forma da lei complementar' ou 'nos termos da lei complementar'. Caso contrário, pode ser lei ordinária. Para se ter uma ideia, existem mais de 14 mil leis ordinárias e menos de 200 leis complementares; logo, é muito mais comum a promulgação de leis ordinárias.

A segunda diferença entre lei ordinária e lei complementar é o quórum de aprovação: para lei complementar, o quórum é de maioria absoluta; para lei ordinária, o quórum é de maioria simples.

Reserva legal simples x qualificada

Quando não existe direcionamento constitucional, a reserva legal é simples. Por outro lado, na reserva legal qualificada, o papel do legislador é afunilado. Exemplo de reserva legal qualificada: o sigilo de comunicações telefônicas é inviolável, de modo que o uso de escuta ou grampo só pode ser utilizado mediante determinação judicial. De acordo com a Constituição, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas só é possível nas hipóteses e prazos previstos em lei, para instruir investigação criminal ou processo penal. Logo, a interceptação se limita à esfera penal, de modo que, se o sujeito estiver devendo pensão alimentícia, não pode ocorrer interceptação telefônica nem se estiver previsto em lei. Não é permitido deferir interceptação telefônica para as esferas cível ou administrativa.

A reserva legal pode ser absoluta ou relativa.

- Reserva legal absoluta: o tratamento é exclusivamente por meio de lei.
- Reserva legal relativa: a lei estabelece uma moldura, que pode ser preenchida com um decreto.

(Im)possibilidade de Medida Provisória em Direito Penal

O art. 62, § 1º, da Constituição, dispõe que as seguintes matérias não podem ser tratadas por medida provisória: direito penal, processo penal e processo civil, direitos políticos, nacionalidade, cidadania, direito eleitoral.

A parte que proíbe medida provisória em direito penal entrou no texto constitucional por meio da Emenda n. 32/01. No entanto, existe uma discussão acerca da possibilidade de medida provisória em direito penal nos casos em que ela favorecer o acusado. Em termos de texto constitucional, essa possibilidade não existe, independentemente da circunstância. Contudo, existe precedente do STF, o qual permite quando se trata de normas não incriminadoras (normas favoráveis).



10m

ANOTAÇÕES

Exemplo: o Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), que previa a possibilidade de as pessoas entregarem as suas armas ao Estado sem incorrerem em crime. Em 2008, esse prazo foi estendido por meio de medida provisória.

Exame psicotécnico em concursos públicos (SV 44)

É permitido o exame psicotécnico em concursos públicos. Por conta de critérios incertos, indeterminados e subjetivos, muitas pessoas que eram reprovadas no exame psicotécnico entravam na justiça e geralmente acabavam ganhando a causa. Atualmente, o STF tem o entendimento de que, se forem observadas as seguintes balizas, o exame psicotécnico é válido e não pode ser questionado na justiça: previsão em lei, previsão no edital, critérios objetivos de correção e a possibilidade de recurso na via administrativa.

Limite de idade e de altura em concurso público (STF, Súmula 683)

É possível estabelecer limite de idade e de altura em concurso público, desde que a limitação se justifique pela natureza do cargo.

Considere os seguintes casos que chegaram ao STF:

Cargo	Legislação correspondente	Limite de idade estabelecido
Juiz do DF	Lei ordinária federal	Mínima: 25 anos Máxima: 50 anos
Juiz da BA	Lei complementar estadual	Mínima: 21 anos Máxima: 60 anos

Ambos os casos foram declarados inconstitucionais pelo STF, pois os requisitos para ingresso em cargos no âmbito da magistratura devem estar previstos em lei complementar federal de iniciativa privativa do STF.

A inconstitucionalidade dos casos acima era formal, mas, para o STF, também havia a presença de inconstitucionalidade material. A limitação de idade não se justificava pela natureza do cargo.

A limitação se justifica em carreiras da área militar e de segurança pública. Ademais, na área militar, existe limitação quanto à altura para homens (1,65m) e mulheres (1,60m). Contudo, mesmo na área militar, a depender da área de atuação (exemplo: quadro auxiliar da saúde nas Forças Armadas), a limitação de altura não tem cabimento.

ANOTAÇÕES

Tatuagens

Como regra geral, o edital do concurso não pode proibir tatuagens, mesmo que ela apareça fora da farda. Contudo, a depender da mensagem da tatuagem, essa proibição é legal. Exemplo: tatuagem de suástica ou tatuagem de palhaço, a última comumente utilizada como um símbolo de que o indivíduo matou um policial. Se a mensagem contida na tatuagem for contrária aos ideais republicanos ou aos ideais da corporação, o candidato pode ser eliminado do concurso.



20m

Lei ordinária x lei complementar

A Constituição Federal traz 50 hipóteses nas quais a lei complementar deveria ser utilizada. Se porventura a Constituição estadual trouxer 60 hipóteses, as situações de lei complementar podem ser alargadas? O STF entendeu que o constituinte estadual não pode exigir lei complementar sobre matéria não pedida pelo legislador federal.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Julgue o item a seguir.
A exigência de exame psicotécnico dispensa lei em sentido formal.



COMENTÁRIO

A exigência de exame psicotécnico não dispensa lei em sentido formal, de acordo com a Súmula Vinculante 44.

GABARITO

1. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.